

1500088-28.2021.8.26.0551
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ricardo Truite Alves
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/03/2022
... consume.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500088-28.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500088-28.2021.8.26.0551
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056802/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 16481897 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 526/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2056802 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 526/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Justiça Gratuita
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

JOSÉ JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 26 de fevereiro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Eusébio Vilar, nº 236, Parque Nossa Senhora das Dores IV, nesta cidade e comarca de Limeira/SP, o acusado adquiriu e mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 240 flaconetes preenchidos com cocaína, pesando 21,22g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, o acusado recebeu e mantinha escondido grande quantidade de

cocaína no quarto de sua residência, para desenvolver o comércio ilícito de drogas no bairro Parque Nossa Senhora das Dores IV e proximidades.

Na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento pelo bairro supramencionado, receberam informação de que o acusado realizava tráfico de drogas e guardava entorpecentes em sua casa. Em diligências pelo bairro, os agentes públicos localizaram o acusado em sua barbearia, utilizando um veículo VW/Gol, cor vermelha, conforme a informação relatada.

Em seguida, os policiais abordaram o acusado e com ele encontraram a quantia de R\$14,00. Na ocasião, o acusado confessou informalmente que mantinha drogas em sua residência para fins de tráfico. Logo após, os agentes públicos dirigiram-se até a residência do acusado. Chegando ao imóvel, o próprio acusado, sua mãe e seu tio franquearam o acesso à residência e acompanharam a diligência.

Durante revista no imóvel, foram localizadas, dentro da gaveta da cômoda do quarto do acusado, os 240 flaconetes preenchidos com cocaína, onde o acusado havia guardado para posterior entrega ao consumo de terceiros. Ainda, em um pote sobre a mesma cômoda, foi localizada a quantia de R\$1.655,00.

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 220/226).

A denúncia foi recebida em 14 de julho de 2021 (fls. 255/257).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 426/431) e da Defesa (fls. 432/445).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analiso as preliminares levantadas pela Defesa.

Não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar.

Como se sabe, a inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia.

A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. Assim, o contexto de flagrante delito e o estado de necessidade de terceiros (socorro ou desastre) prescindiriam do consentimento expresso do morador.

A configuração do flagrante delito, como se sabe, é uma das hipóteses autorizadoras do ingresso no domicílio alheio. Aqui, no conflito emergente entre a privacidade e o resguardo imediato da ordem pública, o legislador inclinou-se em favor do último.

Assim, da hipótese daquele que é surpreendido no momento em que comete a prática delituosa ou que acaba de cometê-la (flagrante próprio), àquele que é encontrado logo depois, em poder dos objetos ou instrumentos do delito (flagrante presumido), passando pela situação de perseguição imediata e ininterrupta (flagrante

impróprio), conferiu o legislador mandamento aos agentes públicos para efetivarem a prisão, independentemente de ordem judicial (art. 302 do CPP).

Ora, se a custódia em tais casos é executada diretamente, natural que o ingresso no domicílio também possa se dar diretamente até mesmo para a concretização daquela prisão.

Então, não houve violação de domicílio, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Não bastasse, cabe ainda chamar a atenção que, no caso concreto, havia fundadas suspeitas da prática de crime do tráfico no local a autorizar a ação da polícia militar.

De fato, revelou a prova oral que a diligência policial questionada pela Defesa foi precedida de abordagem prévia do acusado numa barberaria. Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas, quando receberam a informação de que o acusado realizava tráfico e guardava drogas na sua residência.

Feita a abordagem, em poder dele houve a localização de dinheiro. Indagado, ele confessou que mantinha drogas no interior da sua residência.

Em razão desses fatos, houve buscas no interior da residência (entrada franqueada pelos familiares) e os agentes públicos localizaram, dentro da gaveta da cômoda do quarto do imputado, cerca de 240 flaconetes contendo cocaína. Ainda, em um pote sobre aquela cômoda, foi localizada a quantia de R\$1.655,00.

Em resumo, o réu estava em comportamento típico de tráfico, mas foi interrompido pela ação da polícia militar, havendo prisão em flagrante.

Os elementos trazidos pelos policiais militares corroboraram a fundada suspeita da ocorrência de crime de tráfico no imóvel residencial ocupado pelo denunciado, com o encontro de drogas e quantia em dinheiro, de crime considerado permanente, o que justificou a busca e apreensão sem mandado judicial.

Havendo, portanto, sérios e concretos indicativos da prática de tráfico no local dos fatos, não há que se falar em afronta à tese firmada em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário 603.616 do Colendo Supremo Tribunal Federal (tema 280):

“Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Não é outro o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, a saber:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CRIME – FLAGRANTE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, surge lícita a entrada forçada em domicílio sem prévia autorização judicial”. (STF, HC 177923, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO

"Agravamento regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crime de tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Exceção. Situação de flagrante delito. Controvérsia acerca do ingresso de policiais no domicílio (...). 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (RE nº 603.616-AgR/RG – Tema 280). 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via processual do habeas corpus. Precedentes. (...) 5. Agravamento regimental não provido". (STF, HC 197268 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. (...) INVOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares. 3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes. 4. Agravamento regimental desprovido". (STF, ARE 1312140 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

"Penal e processual penal. Agravamento regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, com fundamento nas provas produzidas e submetidas ao contraditório, reconheceram a inexistência de entrada forçada no domicílio do recorrente, identificando a prévia justa causa para o ingresso por parte dos policiais (...). 4. Agravamento regimental a que se nega provimento". (STF, HC 198582 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021).

A respeito do consentimento dos moradores, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.342.077/SP (Julgamento: 02/12/2021. Publicação: 06/12/2021), reafirmou a tese fixada no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), ao assentar:

"O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O entendimento adotado por essa Suprema Corte impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante".

Na mesma decisão, o Ministro Alexandre de Moraes anulou o venerando acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021) que exigia consentimento do morador comprovado por documento escrito da diligência policial e gravação audiovisual, eis que tais exigências consubstanciam inovação em matéria constitucional e implantação obrigatória de medidas não previstas em lei, que são atinentes à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas.

Embora a Defesa sustente que os depoimentos das suas testemunhas confirmariam a tese de que o ingresso na residência teria sido ilegal, anote-se que a genitora e o tio do acusado sequer foram ouvidos em juízo para confirmar a versão de que não deram qualquer consentimento para o ingresso dos agentes públicos.

Desse modo, deve ser dada prevalência ao depoimento dos policiais militares, que se mostraram firmes e uníssonos quanto ao consentimento dos moradores, como adiante se verá.

A conduta do acusado, como mencionada na denúncia, de ter em depósito entorpecente para entrega a consumo de terceiros, caracteriza o delito de tráfico de drogas. É prescindível que o agente seja surpreendido praticando atos de comércio, por não ser a venda a única conduta existente no tipo penal mencionado no artigo 33 da Lei de Tóxicos.

O comércio ilícito de drogas tem na clandestinidade uma de suas principais características, o que dificulta a sua repressão. Os meios usuais de prova (testemunhal e documental) quase sempre se revelam pouco concludentes.

Logo, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, muito menos em falta de consentimento dos moradores como pretende a combativa Defesa.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 22/23), auto de exibição e apreensão (fls. 25), laudo pericial com resultado positivo para "cocaína" (fls. 29/31 e 135/137), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas. Negou que tinha drogas em seu quarto. Anotou que outra equipe policial havia entrado em sua casa. Alegou que o dinheiro apreendido em seu quarto é proveniente da venda das rodas de um carro (fls. 07).

Em Juízo, o réu contou que tem 26 anos. Está desempregado. Faz tratamento de tuberculose. No dia dos fatos estava na barbearia. Recebeu a notícia que sua casa estava sendo invadida pelos policiais. Na casa não havia mais viaturas. Voltou à barbearia. Depois policiais foram na barbearia. Foi enquadrado. O cliente foi liberado. Foi colocado dentro da viatura, não tinha documentos. Foi levado até a sua casa. Os policiais não deixaram ele entrar. Sua mãe chegou. Não reconhece essa droga localizada. O dinheiro é decorrente da venda de rodas de um veículo. Não sabe de quem é esse entorpecente. Só viu a droga quando foi apresentada na delegacia. Não tem envolvimento com o tráfico, isso foi coisa do passado. Quer ter uma nova vida. Ficou cerca de seis meses preso. Não conhecia os policiais até então. Não autorizaram o ingresso na casa. Estava na barbearia e cortava cabelo. Ninguém da

sua casa autorizou a entrada. Falaram que era uma averiguação normal. Da abordagem até ser levado à delegacia demorou cerca de uma hora. Ficou dentro da viatura quando os policiais reviraram a sua casa. Foram duas equipes. Precisa de tratamento constante por conta da tuberculose. Também tem problemas com outras doenças. Sua saúde piorou muito com a sua prisão. Ficou no hospital penitenciário por dois meses e depois foi transferido para outro local da capital por mais quatro meses. Ficou de cadeira de rodas, perdeu movimento das pernas. Sua mãe está gastando muito com remédios caros. Hoje passa por diversos tratamentos (mídia).

Vejam os fatos da prova oral, contrária aos interesses do réu.

O policial militar Clecio Caitano da Silva contou que faziam patrulhamento pela cidade de Limeira. Receberam denúncia de popular informando que o réu traficava drogas. É que ele possuía um veículo Gol, de cor vermelha, com lanterna esquerda quebrada. Deparam-se com o automóvel estacionado, defronte a uma barbearia. Indagaram se ali estaria a pessoa de Jefferson. Pediram pra ele sair do local. Fizeram busca veicular, mas nada foi localizado. A mãe do acusado compareceu. Foram até a casa dela e lá estavam o tio e a mãe, ambos franquearam a entrada. Localizaram drogas numa gaveta e dinheiro no pote. Ele assumiu a posse das drogas. A quantia era de R\$1.655,00 e eram vários flaconetes de cocaína. Ele confessou que os entorpecentes eram pra fins de tráfico e já estava tudo preparado para o comércio. Não se recorda quando ele falou que tinha drogas na casa. Trabalhou em outras cidades, mas não em Limeira. Era o comandante de equipe. Somente essa equipe participou da ocorrência. A informação de que o réu era traficante veio de um transeunte, era um homem, de perfil normal. Não registrou essa informação em qualquer relatório, não é praxe dele, pra isso tem disque denúncia. Não havia câmeras. Não gravou a ocorrência por celular. Não vistoriou o estabelecimento da barbearia, só pediu pra ele sair de lá. Acompanharam a genitora do réu até a casa dela. Houve consentimento para ingresso na casa, está tudo no boletim de ocorrência da polícia militar. Na frente da casa não havia ato de tráfico. Ele e seu parceiro localizaram as drogas e estavam os entorpecentes no interior de uma gaveta. Não localizou anotações de tráfico. Só entrou na casa do acusado, não viu se era casa geminada. Não se recorda a cor da droga. A casa estava vazia, entrou com a mãe dele (mídia).

O policial militar Leandro Tadeu Pires da Silva contou que estavam em patrulhamento pelo bairro. Receberam denúncia de populares de que uma pessoa parda, de vulgo Jefinho, realizava tráfico pelo bairro. Para tanto ele fazia uso de um veículo Gol bola, de cor vermelha, com farol quebrado. Em determinado momento viram o acusado parado defronte a uma barbearia. Chamaram a pessoa. O acusado disse que era ele. Ele saiu do local, fizeram busca nele e no veículo. A mãe do réu chegou. Como ele não portava qualquer documento, foram até a casa dele pra retirar documentos e qualificação. Na casa dele, com a devida autorização da mãe dele e do tio, ingressaram no local. No quarto dele, numa cômoda, localizaram duas embalagens contendo drogas, divididas, eram flaconetes contendo cocaína. Sobre a cômoda havia dinheiro. Indagado, ele disse que traficava por lá. Na detenção passaram pelo hospital porque o réu tinha problemas no ciático, na coluna. Depois foram ao plantão policial. Acredita que houve apoio de outra viatura. Quem deu a informação de que o réu era traficante foi populares, mas eles não foram qualificados. Não se recorda das características de quem relatou. A denúncia foi pessoal. A mãe do acusado autorizou a entrada. Foram pegar documentos e confirmar a denúncia. As drogas estavam numa cômoda, eram duas embalagens dentro de uma gaveta. O dinheiro estava em cima da cômoda. Não localizou anotações de tráfico. Não se recorda se tiraram fotografias das drogas e do dinheiro. O réu disse que realizava a venda de drogas, ele não falou nada da venda de rodas de veículo (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais militares, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

A Defesa arrolou testemunhas.

A testemunha Juliana Bezerra disse que é vizinha do acusado. Viu os policiais chegando na casa. Estava na sua residência, ouviu um barulho de caminhão. Quando saiu para fora os guardas entraram na casa dele. Não tinha mais alguém dentro da casa. Não foi pedida autorização da genitora do acusado, não tinha nenhum familiar do acusado junto com os guardas. Havia uma viatura e depois chegou outra viatura. Foi a segunda viatura que trouxe o acusado. Não viu a mãe do réu na segunda viatura. A primeira viatura ficou na casa por volta das duas e meia até as três horas. O réu era o inquilino do fundo. Surgiu boato dele ser traficante. Ali não tem tráfico de drogas e nem o réu é envolvido com a traficância. Sabe que o acusado é uma pessoa muito doente, ele é cuidado pela genitora e não consegue trabalhar. Não viu qualquer documento sendo entregue pela polícia. A distância da barbearia até a casa dele dá em torno de cento e cinquenta metros, fica na rua de trás. Isaias era inquilino do fundo e ele morava lá há pouco tempo. Isaias não tinha parentesco com ninguém da casa. Não sabe o nome dele e nem onde ele mora, hoje ele não mora mais. Sabe o nome da mãe e do padrasto, eles estavam trabalhando naquele dia (mídia).

A testemunha Rosimeire de Souza Pereira disse que é vizinha do acusado. Foi ouvida como informante. Nunca viu ocorrer tráfico naquele local, muito menos pessoas indo buscar drogas e dinheiro lá. Nunca ouviu boatos contra o denunciado. Quem mora ali são pessoas trabalhadoras, é uma casa de família. Sabe que o acusado tem problemas de saúde e não consegue trabalhar, inclusive tem tuberculose. Isaias mudou do local e não tem contato com ele. Não foi autorizada qualquer entrada, viu a mãe do acusado chorando. Eles entraram sem que ela estivesse lá, ela havia chegado do serviço. Ali perto há uma barbearia (mídia).

A testemunha Isaias Sebastião de Souza disse que alugou uma casa em Limeira. Estava mexendo no telefone quando sua casa foi invadida por policiais. Suas coisas foram vasculhadas. A casa do acusado foi invadida. A edícula fica ao fundo. Os policiais não pediram permissão. Na casa de Jefferson não havia qualquer pessoa. Ninguém autorizou a entrada. Os policiais não deixaram que ele acompanhasse a revista. Só mora família. Nunca viu o acusado cometendo crimes, nem ouviu boato. Sabe que o réu

tem problemas de saúde por comentários da genitora. Chegou uma outra viatura depois. Os vizinhos não viram a ação da polícia. Ficou na casa o tempo todo. Estava com sua filha de dois anos de idade. Não foi apresentado qualquer mandado. Não tem cômodos em comum entre eles. Não viu se Juliana ou Rosimeire apareceram. Não conhece elas. Como estava dentro pode acontecer de não ter visto pessoa na outra casa. Não sabe dizer se o tio ou a mãe de Jeferson estavam presentes, como estava no interior da residência não tem certeza de nada (mídia).

Pois bem.

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais militares receberam denúncia anônima informando que o acusado realizava o tráfico de drogas no bairro Parque Nossa Senhora das Dores IV e proximidades. Em diligências pelo local indicado, o acusado foi localizado em sua barbearia, onde foi abordado.

Em busca pessoal, os policiais encontraram R\$14,00 em poder do acusado. Após autorização, os policiais fizeram busca domiciliar e encontraram, no quarto do acusado, 240 flaconetes contendo cocaína, além da quantia de R\$1,655,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao acusado.

Assim, respeitado o entendimento da combativa Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico imputado ao acusado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína, embalada individualmente), a conduta do acusado quando da prisão, as circunstâncias, a denúncia anônima e o encontro de vasta quantia em dinheiro sem justificativa, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...)

(TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

“Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos policiais militares para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Por outro lado, não foram arroladas testemunhas de Defesa que corroborassem a versão do acusado de não ter qualquer envolvimento com a traficância ilícita, devendo prevalecer o relato dos policiais militares que encontraram as drogas no cômodo dele e o prenderam em flagrante delito.

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consume.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis ao réu por possuir maus antecedentes (Execução nº 1.142.032 e autos nº 0005005-28.2014.8.26.0320 – fls. 33/34 e 35/40), devendo a pena-base partir 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

De fato, observo que o acusado ostenta condenação anterior com o decurso do prazo depurador da reincidência, que, a despeito de não caracterizar a agravante, se presta a configurar maus antecedentes.

E o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no Resp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Não há agravantes ou atenuantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

A causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não deve ser aplicada em razão do acusado ostentar maus antecedentes.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente que adoto como razão de decidir:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (...) 5. Dosimetria da pena 6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). (...)". (TJSP; Apelação 0004783-35.2014.8.26.0296; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Fixo a pena final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pela natureza e quantidade da droga em discussão (cocaína), nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado. Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional das penas em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JOSÉ JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Autorizo o apelo em liberdade, pois respondeu solto a este processo.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe. Decreto o perdimento dos bens apreendidos.

P.R.I.

Limeira, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA